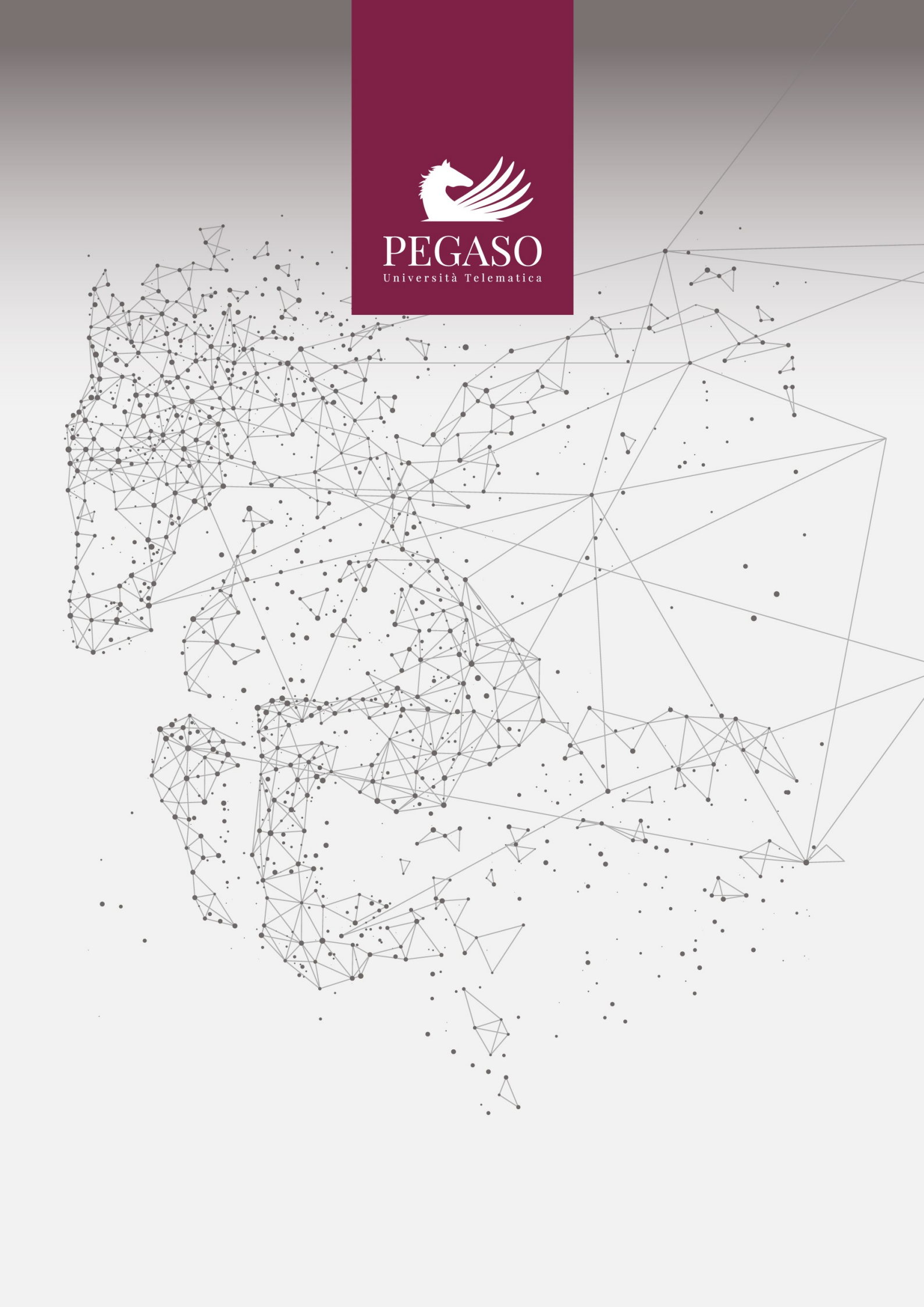

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1 LA RESPONSABILITÀ DELL'ISP ..... 3**
**2 IL LINKING NON AUTORIZZATO ..... 5**
**3 I CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ ..... 7**
**4 I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE ..... 11**
**BIBLIOGRAFIA ..... 18**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1 La responsabilità dell'ISP

Il tema della responsabilità dell'ISP è stato nel tempo oggetto di importanti applicazioni giurisprudenziali.

Rinviando ad altra lezione per la analitica illustrazione delle norme di riferimento, i principi generali e le regole di dettaglio che disciplinano la materia possono essere efficacemente illustrati mediante alcune importanti applicazioni giurisprudenziali.

In specie, risulta interessante esaminare una recente decisione del Tribunale di Roma, anche perché la stessa dimostra come l'ISP possa essere chiamato a risarcire i danni non solo derivanti dalla lesione del diritto d'autore, ma anche di altri diritti della personalità (come l'immagine, il nome, l'onore, la reputazione, ecc.)[1].

Il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità del *social network* Facebook - segnatamente della statunitense Facebook Inc. e della europea Facebook Ireland - per la intervenuta pubblicazione di contenuti audiovisivi di terzi tramite *link* non autorizzati e idonei a condurre l'internauta sulla nota piattaforma YouTube dove i medesimi contenuti erano disponibili.

In specie, accadeva che nel 2012 venisse creata - a opera di utenti rimasti estranei al giudizio - una pagina su Facebook avente ad oggetto il cartone animato Kilari (dal titolo "Valentina Ponzone nei panni di Kilari è assolutamente ridicola") nella quale venivano "postate" immagini della cantante in una con diversi *link*, appunto, che rendevano immediatamente disponibile la visione, in *streaming*, di due video presenti su You Tube che riproducevano la sigla, "interpretata" dalla cantante sia vocalmente sia fisicamente (mediante la ripresa della sua figura mentre ballava e la sua sovrapposizione alle immagini di animazione presenti nella sigla stessa).

Inoltre, su detta pagina erano stati pubblicati insulti pesantissimi da utenti diversi da coloro che avevano creato la pagina medesima, rivolti alla cantante e alla stessa RTI.

[1] Trib. Roma 5 febbraio 2019, in *Il Diritto Industriale*, 2019, p. 377 ss., con nota di B. TASSONE, *Responsabilità del provider per linking abusivo e criteri di liquidazione del danno.*

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Queste, pertanto, agivano in giudizio per richiedere (oltre alle inibitorie e alle *astreintes* di rito per ogni futura violazione) il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti: la sola R.T.I per lo sfruttamento non autorizzato dei diritti (i) d'autore (quale cessionaria per il territorio italiano) e connessi (quale emittente televisiva) relativi al suddetto cartone animato giapponese, (ii) sul nome, sulla voce e sull'immagine dell'artista e ancora (iii) sul marchio italiano e comunitario "Italia 1" di cui era titolare R.T.I., quantificati in euro 250.000; ed entrambe le attrici per la lesione (iv) dell'immagine imprenditoriale della stessa R.T.I. e (v) dell'immagine, dell'onore, del decoro e della reputazione dell'artista, anche qui quantificati in euro 250.000.

Nonostante l'invio di ben cinque diffide, Facebook aveva mantenuto pubblica la pagina in questione per circa due anni prima di rimuoverla.

Nell'affermare la responsabilità del *provider* e nel liquidare il conseguente danno in misura ben più ridotta di quanto richiesto dalle attrici, la pronuncia offre uno spaccato delle regole vigenti per accertare l'*an* e liquidare il *quantum* legato agli illeciti commessi in rete a seguito dell'uso di *link* a contenuti presenti su pagine di terzi.

Inoltre, la decisione in commento merita altresì menzione per la ormai acquisita conferma della doppia dimensione - patrimoniale e non - che i diritti della personalità possono avere, sicché la loro violazione può dare vita al ristoro di un danno sia patrimoniale sia non patrimoniale anche in ragione dello "statuto" che il secondo ha ormai acquisto in base alle decisioni delle Sezioni Unite in materia[2]

[2] Il riferimento è a Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, fra le altre in *Corr. giur.*, 2003, 1017, con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona*; in *Danno e resp.*, 2003, 816 ss., con note di F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d'estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*, G. PONZANELLI, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, e A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *L'art. 2059 c.c. va in paradiso*; nonché a Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, 26972-75, la prima delle quali (con motivazione sovrapponibile a quella delle successive) si legge fra le altre in *ibid.*, 2009, 19, con note di S. LANDINI, *Danno biologico e danno morale soggettivo nelle sentenze della Cass., sez. un., 26972, 26973, 26974, 26975/2008*, e di C. Sganga, *Le sezioni unite e l'art. 2059 c.c.: censure, riordini e innovazioni del dopo principio*, oltre che in *Corr. giur.*, 2009, 48. Circa il doppio rilievo che la violazione di cui nel testo può avere - affermato già all'indomani del primo arresto appena citato – si veda B. TASSONE, *La parabola del diritto all'immagine: dal* right of publicity *al risarcimento del danno non patrimoniale*, in nota a Trib. Tortona 24 novembre 2003, *ibid.*, 2004, 540 ss.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2 Il linking non autorizzato

Con riferimento al profilo di cui in epigrafe, il tribunale recepisce integralmente il *decisum* della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di pubblicazione di opere di terzi tramite attività - appunto - di *linking* non autorizzato dal titolare dei diritti[3].

Invero, è ormai insegnamento ricevuto quello per cui una tale attività rappresenta un atto di comunicazione al pubblico che, come tale, presuppone - ai fini dell'utilizzo dei materiali protetti - la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti, in quanto "l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29"[4]; e in quanto "la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore deve essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera"[5].

Viene data dunque continuità alla giurisprudenza dei giudici di Lussemburgo la quale ha chiarito le condizioni in presenza delle quali la messa a disposizione del pubblico di opere protette tramite la pubblicazione di cc.dd. *hyperlink* deve ritenersi illecita: in assenza di specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti - precisa il giudice capitolino - essa costituisce atto di comunicazione dell'opera "verso un pubblico nuovo perché diverso da quello in origine autorizzato dall'attrice. Ed infatti i *link* pubblicati attraverso la pagina Facebook conducevano non a materiali pubblicati dalla stessa RTI, bensì a materiale pubblicato attraverso un sito terzo (YouTube) non autorizzato da RTI alla diffusione dei materiali audiovisivi in questione".

[3] Si vedano, fra le altre, la sentenza 26 aprile 2017, C-527/15, resa nel caso *Filmspeler*, fra le altre in *AIDA*, 2017, 801 ss., nonché la recente sentenza 7 agosto 2018, C- 161/17, in *www.curia.europa.eu*, 2018, resa nel caso *Renckhoff*.

[4] Corte di Giustizia UE 26 aprile 2017, cit.

[5] Corte di Giustizia UE 7 agosto 2018, cit.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Inoltre, dopo aver ricordato che il diritto patrimoniale d'autore inerente alla comunicazione al pubblico è ovviamente previsto anche dalla l. n. 633/1941 - al suo art. 16 - per come a suo tempo novellata, va pure rammentato che le decisioni della Corte di Giustizia citate in nota sono (con gli adattamenti necessitati dalla diversità delle fattispecie di volta in volta considerate) in linea con la complessiva elaborazione dei giudici comunitari. Tale dato è di immediata evidenza, ad esempio, considerando la decisione resa nel caso "Stiching Brein" inerente alla piattaforma "The Pyrate Bay", in cui la Corte di Giustizia ha affermato che la comunicazione al pubblico "comprende la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete tra utenti", perché - volendo indicare alcuni degli indici ritenuti rilevanti e che non devono essere necessariamente compresenti - (a) senza tale intervento gli utenti non ne potrebbero fruire, (b) il numero dei destinatari è "considerevole", (c) si tratta di un pubblico "nuovo", (d) l'attività è lucrativa[6].

[6] Corte di Giustizia UE 14 giugno 2017, n. C-610/2015, fra le altre in questa *Dir. ind.*, 2018, 175, con nota di A. LA ROSA e D. RONCARÀ, *Il portale* web *è responsabile dei contenuti messi a disposizione del pubblico anche quando non li ospita direttamente*.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3 I criteri di accertamento della responsabilità

Una volta acclarato che la condotta è di per sé illecita perché viola il diritto esclusivo di sfruttamento sull'opera previsto dal diritto d'autore occorre stabilire se Facebook ne debba, o no, rispondere, giusta gli speciali criteri dettati dal noto d.lgs. n. 70/2003, attuativo della Dir. CE 31/2000[7].

Nello specifico, il Tribunale di Roma riconosce la responsabilità della Facebook Inc. "per aver concorso, quantomeno con condotta omissiva, alle violazioni poste in essere dagli utenti che hanno fattivamente creato il profilo Facebook in contestazione".

Infatti, la decisione considera espressamente il fatto che secondo la CGUE "anche in riferimento al semplice prestatore di un servizio dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio medesimo (c.d. hosting passivo)", va esclusa l'esenzione di responsabilità prevista dall'art. 14, dir. 31/2000 quando lo stesso "dopo avere preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari, abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi", così sancendo il principio secondo il quale la conoscenza, comunque acquisita, dell'illiceità dei dati memorizzati fa sorgere la responsabilità del prestatore di servizi[8].

Inoltre, il giudice romano richiama altresì il considerando 48, dir. 2000/31, il quale prevede la possibilità, per gli Stati membri, di "chiedere ai prestatori di servizi che detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio, di adempiere al dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite", sicché la "conoscenza dell'illiceità dei dati memorizzati, comunque acquisita

[7] Posto che sull'argomento la letteratura è sterminata, sia consentito rinviare ai riferimenti contenuti in G. CASSANO e A. ROVATI, *La c.d. neutralità del web non più elemento di sfruttamento dei diritti d'autore altrui*, in nota a Trib. Roma, 10 gennaio 2019, in *Diritto di Internet*, 2019, 140 ss.

[8] Per tutte, Corte di Giustizia UE 23 marzo 2010, cit.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

(anche mediante un'informazione fornita dalla persona lesa), fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria del prestatore di servizi".

Ne deriva che in base al noto criterio del "*notice and take down*" l'inerzia protratta in modo ingiustificato è sempre fonte di responsabilità, indipendentemente ed ancor prima dall'esistenza di un ordine dell'autorità, come affermato - ancora una volta - dalla Corte di Giustizia[9]. Pertanto, a prescindere dal ruolo svolto nel caso concreto da Facebook, "anche il c.d. *hosting provider* passivo non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso dai fruitori del suo servizio, deve attivarsi al fine di consentire la pronta rimozione delle informazioni illecite immesse sul sito o per impedire l'accesso ad esse, in quanto egli è tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto di quella diligenza che è ragionevole attendersi per individuare e prevenire le attività illecite specificamente denunciate".

Infine, è da notare che - menzionando un altro "topos" della complessiva elaborazione giurisprudenziale in materia, segnatamente in punto di oneri di allegazione - viene pure disattesa l'eccezione a tenore della quale le diffide trasmesse da RTI non erano sufficientemente dettagliate, in quanto non contenevano gli URL dei contenuti censurati[10]. Tale difesa viene invero ritenuta dalla Corte "del tutto priva di pregio giuridico", dacché secondo il Collegio giudicante

[9] Fra le tante, Corte di Giustizia UE 12 luglio 2011, cit., a tenore della quale "affinché non siano private del loro effetto utile, le norme enunciate all'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretate nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze".

[10] Senza pretese di completezza, è invero il tema relativo alla necessità di indicare specificamente l'URL ovvero solo le opere protette. Nel primo senso, ad esempio, Trib. Roma 11 luglio 2011, in *AIDA*, 2013, 664 ss., Trib. Torino 6 maggio 2014, *id.*, 2015, 773 ss. e App. Milano 7 gennaio 2015, n. 29, fra le altre in *Corr. giur.*, 2016, 811 con nota di I. BASSOLI, *Il diritto d'autore e la responsabilità del provider: evoluzioni tecniche e giurisprudenziali nell'appello Yahoo vs. RTI*, in *Riv. dir. ind.*, 2016, II, 166, con nota di M. IASELLI, *Caso "Yahoo! video": la Corte di Appello di Milano non vede responsabilità nell'operato dell'Internet provider*, nonché Trib. Torino, 7 aprile 2017, in *AIDA*, 2017, 1130. Di contrario avviso, invece, Trib. Roma 27 aprile 2016, fra le altre in questa *Rivista*, 2016, 460, con nota di G. CASSANO, *Sulla responsabilità del* provider *per la diffusione abusiva in rete di opere audiovisive*, nonché App. Roma 29 aprile 2017, fra le altre in *id.*, 2018, 181, con nota sempre di G. CASSANO, *Nozione di* provider *e delimitazione della responsabilità: la giurisprudenza prende una direzione*. In conformità ai principi generali di correttezza e buona fede afferma che "spetta all'ISP l'onere di provare che un contenuto illecito è stato effettivamente rimosso in esecuzione di una richiesta specifica" e "quando il titolare abbia indicato che il contenuto di un URL viola i suoi diritti e l'ISP lo abbia rimosso, il medesimo ISP ha un obbligo generale di rimuovere il medesimo contenuto quando venga rimesso in linea in tutto o in parte, senza che il titolare dei diritti abbia un onere di riavviare il procedimento della diffida previa", Trib. Torino 3 giugno 2015, in *AIDA*, 2016, 951.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

"l'indicazione dell'URL costituisce un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale, ma rappresenta soltanto il 'luogo' dove i contenuti sono reperibili e, quindi, non costituisce un presupposto indispensabile per la loro individuazione".

Inoltre, con Cass. n. 7708/2019 (e la sua "gemella minore" 7709/2019) si è avuta la prima presa di posizione dei giudici di legittimità civili sulla responsabilità dell'ISP.

Quanto al profilo sopra indicato, la Suprema Corte rimette una tale valutazione (circa la necessità della indicazione degli URL) al giudice del merito, dopo essere intervenuta a dirimere una complessa vicenda che ha ad oggetto il tema della violazione del diritto d'autore e che vede protagoniste, da un lato, sempre R.T.I. e, dall'alto lato, Yahoo Inc. e Yahoo Italia, con riferimento alla diffusione sul portale video del noto *provider* di taluni filmati tratti da vari programmi televisivi di cui la prima era unica titolare e su cui vantava diritti esclusivi[11].

Ebbene e per quanto qui interessa, dopo aver operato interessanti distinzioni fra *provider* c.d. "passivo" e "attivo" nonché indicato (sulla scia dell'elaborazione euro-unitaria, cui viene dato il giusto valore) i criteri per distinguere le due fattispecie - viene ribadito che, se può dirsi insussistente un obbligo di sorveglianza e di attivazione anticipato, generale e costante in capo al *provider*, deve al contempo rilevarsi la sussistenza di un obbligo di rimozione ove lo stesso sia a conoscenza dell'illecito commesso dal destinatario del servizio[12].

Ancora, la Suprema Corte sottolinea che la "comunicazione dell'illecito perpetrato" non deve necessariamente provenire da una pubblica autorità, amministrativa o giurisdizionale (che ordini un determinato comportamento o almeno dia notizia dell'illecito al prestatore) e che

[11] Cass. 19 marzo 2019, n. 7708, in *Riv. internet*, 2019, con nota di G. CASSANO, *La Cassazione civile si pronuncia sulla responsabilità dell'ISP*. Per una recente rassegna sugli orientamenti relativi alla responsabilità dell'ISP, R. PANETTA, *Il ruolo dell'*Internet Service Provider *e i profili di responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 1017 ss.

[12] In proposito, è appena il caso di ricordare che anche nel settore di cui si tratta viene troppo spesso dimenticato che le decisioni rese dalla Corte di Giustizia sono esse stesse e di fatto - a valle di ogni riflessione sulla c.d. giurisprudenza normativa - "fonti del diritto", dacché a nessun giudice nazionale è dato di mettere in discussione l'interpretazione che le stesse offrono della normativa euro-unitaria, a sua volta sovraordinata a quella nazionale e tale da conformare (attraverso varie vie) l'ordinamento italiano. Rimane solo da riflettere sui margini di cui l'interprete dispone nel difficile dialogo (non paritario) fra due ordinamenti e le cui regole vengono generate attraverso categorie, *rationes* e lingue assai diverse fra loro, come si è evidenziato in B. TASSONE, *Intellectual Property e Internet: fra problemi di prova e ingiunzione dinamica*, lezione tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura in data 28 marzo 2019, in corso di rielaborazione e pubblicazione.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

l'*hosting provider* è chiamato a delibare, secondo criteri di comune esperienza, nonché alla stregua del parametro della diligenza professionale qualificata, la comunicazione pervenutagli e la sua ragionevole fondatezza (ovvero, il buon diritto del soggetto che si assume leso), dovendosi poi attivare prontamente in caso di esito positivo della verifica.

In ultimo - chiudendo con il citato tema degli oneri di allegazione cui sopra - la Cassazione afferma che l'attore deve quindi allegare e provare, a fronte dell'inerzia dell'*hosting provider*, la conoscenza da parte di detto professionista dell'illecito compiuto dal destinatario del servizio - la quale è indotta dalla stessa comunicazione del titolare del diritto leso o può essere ricavata *aliunde* - nonché indicare gli elementi che rendevano manifesta detta illiceità[13].

Resta però affidato al giudice del merito l'accertamento, in punto di fatto, se, sotto il profilo tecnico-informatico, l'identificazione di video, diffusi in violazione dell'altrui diritto, a) sia possibile mediante l'indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui sono tratti, oppure b) sia indispensabile, a tal fine, la comunicazione dell'indirizzo URL, alla luce delle condizioni esistenti all'epoca dei fatti, occorrendo precisare che "lo stato della tecnica" - probabilmente - è idoneo a far ritenere sussistente la prima alternativa.

[13] E anche qui (come evidenziato nel contributo di cui alla nota che precede) si aprono ampi spazi di riflessione una volta acquisita la consapevolezza del fatto che (per citare i passi della dottrina ripresi dalla cassazione) "il diritto privato Europeo è pragmatico e non si cura delle architetture concettuali, avendo il legislatore comunitario il difficile compito di ottenere effettività con il 'minimo investimento assiologico' ed un 'minimo tasso di riconcettualizzazione'; ed il rilievo, secondo cui le norme di derivazione Europea provengono da sistemi giuridici segnati da una 'tendenziale sottoteorizzazione'": cui si aggiunge la considerazione per cui nel delineare il regime di responsabilità dell'ISP è stata "applicata la massima d'esperienza, tratta dall'analisi economica del diritto, secondo cui delimitare il regime di responsabilità ha l'effetto di sostenere le scelte d'impresa", dovendosi però considerare che la "configurazione tecnica della responsabilità [...] opera [...] sulla c.d. allocazione dei rischi, influenzandola ogni volta in modo diverso [...] come quando come quando si ritenga più efficiente a raggiungere i risultati voluti far gravare la responsabilità sul soggetto che economicamente sia in grado di sostenerla (*least cost insurer*) o si opti per un regime di responsabilità oggettiva, in quanto reputata capace di sollecitare le necessarie cautele preventive da parte di chi potrebbe incorrervi".

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 4 I criteri di quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale

Se la decisione del Tribunale di Roma è pienamente condivisibile con riferimento all'*an*, qualche riserva la suscitano le statuizioni inerenti alla quantificazione del danno.

Partendo dal danno patrimoniale, il tribunale accerta la violazione dei diritti d'autore, connessi e di immagine di cui in premessa, tuttavia circoscrivendo il ragionamento in punto di *quantum*, almeno espressamente, solo ai primi: laddove la attenta considerazione anche degli altri aspetti sarebbe valsa ad assicurare alla responsabilità civile un idoneo effetto deterrente. E ciò - come si dirà fra breve - risponde ad un'esigenza particolarmente sentita nella materia *de qua*.

In effetti, nel tener conto del solo profilo inerente alla violazione del diritto patrimoniale d'autore il tribunale richiama l'art. 158, l. n. 633/1941 - solo in parte omologo all'ancora più incisivo art. 125 del codice della proprietà industriale - e, fra i vari criteri che la norma indica al fine di agevolare il danneggiato rispetto a quanto prevede l'ordinario regime della responsabilità civile, sceglie quello relativo al c.d. "prezzo del consenso"[14].

In proposito, va intanto ricordato che l'art. 13, par. 1, dir. 2004/48/CE prevede due parametri alternativi per quantificare i danni in misura effettiva, cioè quello che considera "tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno della parte lesa, i benefici realizzati illegalmente e [...] elementi diversi da quelli economici come il danno morale", nonché quello che fa leva su "una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso".

E la nostra giurisprudenza si riferisce all'uno o all'altro criterio anche in base alle peculiari circostanze del caso concreto, con quello basato sugli utili percepiti dal contraffattore che non è spesso di agevole applicazione, come dimostra - oltre al caso di specie - quello inerente alla

[14] Si tratta di norme esaminate in altre apposite lezioni.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

piattaforma Vimeo, in cui il calcolo dovrebbe essere basato ad esempio sugli "*sponsored links*" del *provider*, sull'aumento di valore della piattaforma stessa dovuta al c.d. "effetto di rete" o sul ridotto corrispettivo chiesto solo ad alcuni tipi di utenti[15]; e con quello che fa leva sul prezzo del consenso che è tale da poter condurre sistematicamente a sottostimare il danno.

Tale criterio, infatti, può comportare la trasformazione autoritativa del *tort* in *contract* tramite un'impropria "licenza obbligatoria", come è noto estranea al sistema delle privative autoriali e operativa in taluni marginali casi relativi ai brevetti. Sembrerebbe allora opportuno farne

[15] Trib. Roma 10 gennaio 2019, cit., la quale muove dal presupposto per cui "[c]on specifico riferimento al modello di *business* adottato da Vimeo, il CTU ha evidenziato che i canali attraverso i quali Vimeo incamera gli utili sono (i) gli introiti derivanti dalle iscrizioni e dalle transazioni associate alla commercializzazione dei video, (ii) le inserzioni pubblicitarie". Ebbene, con riferimento all'elemento di cui *sub* (iii), le difficoltà di accertamento del danno sono fra l'altro connesse al fatto che "ai video per cui è causa non sono stati associati annunci pubblicitari veri e propri ('*display advertisement*') sotto forma di banner pubblicitari direttamente visibili sulle pagine" e che "Vimeo ha comunque associato agli stessi contenuti collegamenti pubblicitari ('*sponsored links*') a pagine web di terzi, generati automaticamente da algoritmi di Google mediante il servizio chiamato *AdSense*", ma che "[r]ispetto al totale dei ricavi, il CTU ha rilevato che l'ammontare delle entrate economiche generate dai link sponsorizzati associati ai video in questione è trascurabile [e] il CTU non ha considerato i ricavi della pubblicità relativa al *display advertisement* non essendo stati utilizzati per i medesimi video". Con riferimento all'elemento di cui sub (i), si rileva che "le entrate principali possono essere distinte in due categorie: il canone annuale di iscrizione degli utenti Plus, Pro e Business e il compenso applicato alle transazioni generate dai clienti Pro e Business con la vendita/affitto dei video pubblicati", che "[l]a piattaforma di *business* nella quale inquadrare le attività di Vimeo e del tipo "*multi-sided*", tale da far incontrare due o più gruppi di clienti distinti ma interdipendenti", che "la piattaforma crea valore supportando le interazioni fra i diversi gruppi", che "[i]l valore cresce nella misura in cui attira un maggior numero di utenti (c.d. effetto di rete)". Dunque, si osserva che "[t]ali piattaforme sovvenzionano un segmento di clientela che usufruisce del servizio a basso costo o gratuitamente per aumentare gli utenti e creare valore per attrarre utenti appartenenti ad un altro segmento di clientela: utenti paganti. Esse costituiscono un valore per un gruppo di utenti solo se presente anche l'altro gruppo di clienti. In tale contesto, l'accesso ai video per cui è causa era gratuito, infatti il generico utente non doveva sostenere alcun costo per poter fruire degli stessi, fintantoché sono stati on line. Sicché, in considerazione dell''effetto rete', i video in oggetto, considerata la loro popolarità, potrebbero aver aumentato gli utenti della piattaforma Vimeo attirandone di nuovi, quantomeno nella sezione italiana del sito, e quindi creando valore per la società convenuta e per gli utenti paganti". Pertanto, il tribunale romano deve concludere nel senso che "il CTU ha effettuato un calcolo di massima sui possibili introiti che potrebbero aver generato gli '*sponsored links*' abbinati ai contenuti audiovisivi contestati [...] e tenuto conto dell'intero periodo di permanenza di tali contenuti sul portale (dunque anche per il periodo anteriore a qualsivoglia contestazione da parte di RTI) e dei download effettuati dagli utenti, ha stimato i ricavi conseguiti di Vimeo in circa 2.442 USD, al massimo triplicabile nell'ipotesi, assai remota, che l'utente dopo aver visualizzato il video, avesse selezionato tutti i link sponsorizzati associati". Inoltre – prosegue la decisione – "inattendibile rispetto alle dimensioni dell'illecito accertato nella fattispecie concreta sarebbe stata anche la quantificazione degli utili conseguiti da Vimeo attraverso il calcolo dell'aumento di valore della piattaforma digitale sulla base del c.d. 'effetto rete' prodotto dal caricamento dei video in contestazione. Ovvero, attraverso il calcolo dell'aumento di valore della piattaforma nella misura in cui la stessa sia in grado di attirare un maggior numero di utenti che usufruiscono del servizio a basso costo o gratuitamente per aumentare gli utenti appartenenti al segmento di clientela a pagamento".

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

applicazione solo in via subordinata oppure in presenza di un suo evidente "esito minore" ovvero nullo rispetto alla quantificazione cui conduce il primo (come pare suggerire, in modo condivisibile, la decisione in commento), fatta salva la espressa richiesta dell'attore.

In definitiva, non è peregrino il rischio che, se la misura risarcitoria non è gestita in modo attento, per il contraffattore rimane sempre più conveniente perpetrare la violazione, dacché anche in caso di condanna *ex post* lo stesso si troverà a pagare una somma persino minore di quella che avrebbe dovuto sborsare *ex ante* a fronte di una ruvida negoziazione con il titolare dei diritti. E ciò anche senza scomodare in questa sede le riflessioni suggerite dall'analisi economica del diritto a tenore delle quali persino due somme di valore numerico identico ne possono avere uno assai diverso in termini economici: una somma di 100 Lire da pagarsi oggi in forza di un contratto non equivale alla medesima somma di 100 Lire da pagarsi (in futuro) in forza di una sentenza, se non altro perché la seconda (i) è dilazionata nel tempo e, soprattutto, è alquanto incerta sia perché (ii) non è detto che il danneggiato agirà in giudizio, che (iii) riuscirà a fare affermare la responsabilità del convenuto e (iv) sarà in grado di dare una adeguata prova del danno.

Orbene, venendo al caso di specie, il pregiudizio da lesione dei diritti patrimoniali d'autore viene quantificato in euro 8.095 considerando una durata complessiva di 5 minuti dei due video e applicando un corrispettivo di euro 809,50 al minuto per un periodo di due anni.

In specie, rilevata "la difficoltà di individuare dei parametri economici perfettamente adattabili al mercato dello streaming video su internet che si caratterizza per una costante evoluzione dei profili e per un continuo riadattamento dei modelli di business", il CTU aveva individuato il suddetto corrispettivo di euro 809,50 procedendo ad una media di quelli desumibili dalle licenze annuali prodotte da R.T.I. e, dunque, senza fare applicazione della parte più alta della forbice, nonché omettendo ogni riferimento alla usuale componente variabile del corrispettivo.

Inoltre, che un tale approccio possa portare a sottostimare il danno lo dimostra la decisione resa sempre dal Tribunale di Roma nel caso Break Media, in cui il corrispettivo del minutaggio era

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

stato individuato in euro 1.070 desunte da un accordo commerciale nonché in euro 626 ed euro 732,50 desunte invece da due transazioni, il che portava il CTU ad assumere un parametro medio di euro 650[16].

Tuttavia, pur non sapendo se (ma essendo probabile che) anche nel caso di specie fossero stati considerati accordi di natura transattiva, è chiaro che il loro utilizzo al fine di ridurre il corrispettivo medio non è opportuno, perché la somma che viene dalle parti fissata sconta a monte i rischi del contenzioso sopra indicati.

È peraltro possibile pensare che una determinazione più bassa del corrispettivo derivasse nel caso Break Media dal fatto che si trattava di farne applicazione ad oltre 77 minuti di *streaming* tratti da n. 48 sequenze e frammenti di programmi televisivi per 604 giorni, sicché esso portava alla più rilevante somma di euro 72.294,75. E si deve anche dare atto che la decisione resa nel caso appena menzionato ha il merito di incrementarla equitativamente fino ad euro 100.000 per tener conto di alcuni specifici aspetti che rendevano la somma stessa non adeguata.

Tuttavia proprio la considerazione del fatto che (a) il periodo di permanenza di alcuni contenuti era stato maggiore, (b) non tutte le visualizzazioni erano state "intercettate" dal CTU, (c) la componente variabile del corrispettivo era rimasta non determinabile e (d) il "modello di *business*" della stessa convenuta era incentrato quasi esclusivamente sulla vendita di spazi pubblicitari conseguente alla selezione dei video di maggior *appeal*, mette in evidenza il rischio di *under-compensation* solitamente connesso alla liquidazione del danno nel settore di cui si tratta.

Del resto, non può sfuggire come la convenuta avesse dichiarato in corso di causa di aver pagato 400 USD per un video "pregiato" di soli tre minuti.

In ultimo, è ancora più esteso l'esame della contrattualistica rilevante – così come un suo uso "precedenziale", che purtroppo spinge verso il basso la stima del danno - nel caso relativo alla piattaforma di condivisione video "Vimeo".

Il tribunale capitolino considera infatti e fra gli altri (1) una transazione con la RAI che prevede un corrispettivo di euro 1.460 al minuto, (2), una transazione con RTI-RCS Mediagroup che

[16] Trib. Roma 26 aprile 2016, cit.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

prevede un corrispettivo di euro 626,00 al minuto, (3) un accordo con la RAI che prevede, sulla scorta di precise restrizioni temporali, un corrispettivo euro 1.070 al minuto, (4) una transazione con Kit Digital France che prevede un corrispettivo di euro 245 al minuto ma per soli tre mesi (a rigore pari ad euro 980 all'anno, ridotte equitativamente ad euro 500).

Inoltre, la decisione fa espresso riferimento anche al corrispettivo di euro 650 al minuto di cui al caso Break Media, a quello di euro 638 (aumentato equitativamente ad euro 762) al minuto stimato nel caso R.T.I./Gruppo Editoriale l'Espresso[17] ed a quello di euro 670 al minuto individuato nel caso R.T.I./Megavideo[18]: optando però per l'esclusione dal novero degli accordi più rilevanti di quelli raggiunti con l'emittente televisiva nazionale e valorizzando al contrario quelli intervenuti con altre piattaforme digitali *online*, di poi ritenendo "ininfluente al riguardo la circostanza che, in alcuni casi, si tratti di prezzi unitari formatisi in sede transattiva piuttosto che nell'ambito di una libera trattativa".

E in tal modo si perviene alla individuazione di una "*royalty* ragionevole più aderente al caso di specie [...] attraverso la media dei corrispettivi su base annua evincibili soltanto dai due contratti da ultimo indicati, cosi ottenendo un valore medio unitario al minuto [...] di euro 563,00".

Ebbene se qui - ancora di più - si può pensare che il valore unitario del minuto sia quantificato in modo prudenziale in ragione del fatto che l'enorme mole di materiali sfruttati illegittimamente avrebbe portato già così ad un danno di euro 10.092.525,70 (poi, come si vedrà, equitativamente ridotto ad euro 8.500.000), non è da sottovalutare che il *trend* all'abbassamento del valore può avere conseguenze non desiderabili in altri casi, come dimostra quello deciso dalla pronuncia in commento.

Venendo poi al danno non patrimoniale, il collegio ne dichiara la sussistenza - coraggiosamente - *in re ipsa*, nonostante i noti orientamenti della Suprema Corte che, in modo non sempre coerente, affermano a parole che tale categoria non ha cittadinanza nel nostro

[17] Trib. Roma 5 ottobre 2016, in questa *Rivista*, 2017, 61, con nota di R. Panetta, *La responsabilità civile degli* internet service provider *e la tutela del diritto d'autore*.

[18] Trib. Roma 15 luglio 2016, nel caso "Megavideo", in *www.deiure.it*.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

sistema[19]: essa trova però applicazione ora "di fatto" in relazione alla liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale[20]; ora anche "in diritto" in tema di proprietà[21]. Del resto, una volta che si ammetta la possibilità di liquidare il "danno conseguenza" tramite l'impiego, anche in via esclusiva, di mezzi di prova solo presuntivi, è chiaro che si accorcia notevolmente la distanza fra un danno formalmente *in re ipsa* e un danno sostanzialmente tale.

Inoltre, la sentenza in commento dà in astratto la giusta attenzione alle particolarità del caso concreto che devono orientare la liquidazione equitativa e, dunque, tiene conto "della incontestabile gravità delle offese pubblicate, dello strumento di pubblicazione utilizzato (internet), del tempo di permanenza delle pubblicazioni offensive (circa due anni)".

Di qui, anche in considerazione "della limitata notorietà della persona offesa", una quantificazione - in concreto - di appena euro 15.000, cioè una somma che non sembra tale da generare un adeguato effetto deterrente, anche perché nella sua metà, cioè in euro 7.500, viene poi liquidato il danno di immagine patito da R.T.I.

---

[19] Premesso che non è questa la sede per ricostruire la storia della categoria di cui nel testo, fra le decisioni che manifestano la posizione di cui si è detto si vedano le decisioni a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, cit.

[20] Solo a titolo di esempio, si veda P. Petrelli, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 1997, 607 ss. la quale - a seguito dell'esame di circa 500 decisioni pronunciate fra il 1995 e il 1999 - conclude che "solo in pochissime circostanze si va[da] oltre la mera richiesta di risarcimento, a volte neppure specifica, e la deduzione di elementi relativi alla dinamica dell'evento e ai riflessi per l'integrità psicofisica" e che "solamente in una decisione il rigetto della pretesa risarcitoria sembra basarsi sul fatto che le circostanze allegate non inducono a ritenere presumibile una sofferenza a seguito di sinistro".

[21] In effetti, anche decisioni rese in settori della responsabilità civile assai lontani da quello dei diritti della personalità - in cui la categoria è o sarebbe ben più giustificabile - ne fanno tranquillamente uso: così in quello dei diritti reali - come si evince ad esempio da Cass. 12 maggio 2010, n. 11486 (in *Guida dir.*, 2010, 24, 62) -, ove si sostiene che il comproprietario che non venga messo dal possessore, nonostante la richiesta formulata, nelle condizioni di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., ha diritto a essere indennizzato per la compressione del suo diritto e che "qualora sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comproprietari, il danno deve ritenersi *in re ipsa*"; oppure in quello della violazione delle distanze fra costruzioni, in cui si afferma che "al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete [...] il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, [e che] deve ritenersi *in re ipsa*, senza necessità di una specifica attività probatoria" (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25475, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Distanze legali*, n. 15; Cass. 7 luglio 2010, n. 11196, *ibid.*, voce *cit.*; nonché Cass. 16 marzo 2010, n. 6309, ibid., voce *Espropriazione per p.i.*, n. 211). Ancora, afferma in tema di diffamazione che la lesione della reputazione va valutata *in abstracto*, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico e che la sua lesione integra un danno *in re ipsa*, in quanto privativo di un valore della persona umana, Cass. 28 settembre 2012, n. 16543, in *Dir. inf.*, 2013, 27.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

In proposito, il giudice romano sembra seguire formalmente l'orientamento che tende ad operare una liquidazione equitativa c.d. "pura", cioè sganciata da ogni riferimento al danno patrimoniale, laddove alcune decisioni lo quantificano nella metà del danno patrimoniale[22].

Premesso che, in linea di massima, il secondo orientamento pare maggiormente idoneo ad evitare liquidazioni che siano poco più che simboliche, è però evidente che - nel caso di specie - il danno non patrimoniale assume di fatto un valore persino superiore a quello patrimoniale e resta da capire se, per i casi più gravi, una tendenziale equiparazione fra le due voci sarà seguita anche quando il secondo sia da quantificare in misura ben più elevata (cioè se la medesima conclusione sarebbe stata raggiunta ove esso, poniamo, fosse stato di euro 100.000).

Del resto, si è anticipato che nel caso Vimeo il Tribunale di Roma ha ridotto in via equitativa l'ammontare dei danni subiti da RTI da euro 10.092.525,70 a 8.500.000 a fronte di n. 17.926 minuti di contenuti tratti da 2109 video e illegittimamente trasmessi, in specie tenendo conto del minore grado di colpevolezza del contraffattore, che aveva comunque provveduto a rimuovere tempestivamente le opere audiovisive[23]: se il criterio della gravità della colpa può valere ad operare verso il basso, non si vede perché lo stesso - al contrario - non possa essere utilizzato in direzione opposta in altri casi, nonostante tale tipo di considerazioni sono in genere ritenute estranee al tradizionale modo in cui opera la responsabilità civile, alla quale non si attribuisce una funzione punitiva o sanzionatoria.

Tuttavia, una più moderna visione della stessa porta ad affermare che in taluni casi – tutti da definire, ma fra i quali possono rientrare quelli in parola – la responsabilità civile può assolvere anche alla funzione di cui si tratta, accanto a quella deterrente e compensativa[24].

---

[22] Fra quelle che usano il primo criterio App. Napoli 22 agosto 2014, in *Repertorio AIDA*, 2016, Trib. Roma 22 luglio 1994, *id.*, 1995, e Trib. Roma 3 novembre 1993, *id.*, 1994, mentre – fra le seconde – Trib. Milano 11 marzo 2016, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 726.

[23] Trib. Roma 10 gennaio 2019, cit.

[24] Per vari approfondimenti, TASSONE, *Responsabilità del* provider, cit.

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Bibliografia


- G. Cassano e A. Rovati, *La c.d. neutralità del web non più elemento di sfruttamento dei diritti d'autore altrui*, in *Diritto di Internet*, 2019, 140 ss.
- B. Tassone, *Responsabilità del provider per* linking *abusivo e criteri di liquidazione del danno*, in *Il Diritto Industriale*, 2019, p. 377 ss.


PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*